

1514590-74.2021.8.26.0032
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Marcel Peres Rodrigues
Comarca: Araçatuba
Foro: Foro de Araçatuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/07/2022
...

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araçatuba
Foro de Araçatuba
1ª Vara Criminal
Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514590-74.2021.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1514590-74.2021.8.26.0032
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

DIEGO FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 25 de maio de 2021, por volta das 21:25 horas, no estabelecimento comercial "Sorveteria Maribela", situado na Avenida Prestes Maia, nº 137, no Bairro Planalto, nesta cidade, previamente ajustado com uma mulher não identificada, conscientes da ação em comum, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida) contra as vítimas Everson Renan Garcia, Celice Fernandes Garcia e Emily Beatriz Pereira da Silva Jardim, a quantia de R\$ 445,00, pertencente às vítimas Everson Renan Garcia e Celice

Fernandes Garcia.

Recebida a denúncia (fls. 92/93), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação a fls. 137/138.

No decorrer da instrução foram ouvidas as vítimas Emily e Everson e, após, interrogado o acusado (fls. 218/222).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça insistiu na condenação nos exatos termos da denúncia (oralmente, a fls. 220/222), ao passo que o Dr. Defensor requereu a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante genérica da confissão e a compensando com a agravante da reincidência, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, a declaração incidental da inconstitucionalidade material da expressão 2/3 contida no art. 157, § 2º-A, do Código Penal, ou, sucessivamente, a aplicação da norma do artigo 157, § 2º, I, do CP, em sua antiga redação, o afastamento da combinação das causas de aumento de pena e a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da reprimenda (fls. 225/247).

É o relatório do essencial.

Fundamento e D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade da infração veio comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Com efeito, interrogado em Juízo, o réu confessou a prática do delito de roubo. Disse que roubou o estabelecimento, porém o dono registrou o B.O. depois de vinte e quatro horas e não de imediato. Não conhecia o dono do estabelecimento, mas ele o chamou no whatsapp porque já lhe conhecia. Falou para o proprietário que não tinha mais o dinheiro subtraído porque tem quatro crianças, estava desempregado e tinha acabado de sair da cadeia. Usou uma arma calibre 32 no crime, a qual ficou guardada em sua casa. Pelo que se lembra, levou mais de R\$ 800,00 da sorveteria. Deixou a moto de sua propriedade no estabelecimento ao lado e estava sozinho na hora da fuga. Quando entrou na sorveteria, Renan, que estava sentado, levantou-se e foi para trás do balcão. As duas mulheres estavam do outro lado. A câmera do estabelecimento estava a sua frente, mas não a viu. Estava com máscara no rosto, segurava o capacete e vestia blusa de frio do Corinthians. Tirou o revólver e deu voz de assalto. Neste momento, vieram a mãe e a mulher do dono do estabelecimento, que se desesperaram. Não falou para deitarem no chão, mas apenas que queria o dinheiro. O crime foi motivado por dificuldade financeira. Já foi condenado por assalto. A motocicleta era uma Biz vermelha. Possui duas condenações por infração ao artigo 155. Também teve condenação por lesão corporal contra sua ex-mulher. O roubo foi praticado na noite de uma terça-feira e, na manhã de quarta-feira, foi surpreendido por uma mensagem enviada pelo dono da sorveteria. O proprietário começou a falar que havia roubado o estabelecimento dele e lhe questionou sobre o dinheiro. Falou para o dono que não tinha mais o dinheiro e ele, ameaçando entregar o vídeo para a polícia, lhe deu o prazo de vinte e quatro horas para devolver a quantia subtraída. Não sabe como o dono da sorveteria conseguiu o seu número. Decorrido o prazo de vinte e quatro horas, o vídeo do roubo já apareceu no Regional Express, Facebook, SBT, Record e Globo. Após os fatos cometeu outro crime, pelo qual se encontra preso desde o flagrante.

Ouvida em Juízo, a vítima Emily Beatriz Pereira da Silva Jardim bem esclareceu os

fatos. Disse que estava trabalhando no momento do assalto. Estava na cozinha da sorveteria preparando os pedidos do iFood. Celice, sua patroa, estava na frente no caixa pegando os pedidos, então o acusado entrou como um cliente normal e começou a fazer um pedido, mas ele não sabia o que pedir e estava meio confuso. Pediu para Renan buscar o açaí, então ele foi até o salão pegar o açaí e o deixou na cozinha. Quando Renan retornou para sair da sorveteria, o réu foi com a arma para cima dele, falou "é um assalto", apontou a arma para Renan e mandou irem em direção ao caixa. O acusado lhe avistou na cozinha, falou "você também, vem para a frente" e apontou a arma em sua direção. Ficou com Celice e Renan no caixa e o acusado ficou lhes apontando a arma dizendo "passa o dinheiro que vocês têm aí". O réu perguntou sobre os celulares e Renan respondeu que não tinham. Enquanto o acusado pegava o dinheiro, um casal de clientes chegou, então ele pediu para deitarem no chão e depois saiu do local com uma mulher de moto. O réu subtraiu o dinheiro do caixa. A arma era pequena. O indivíduo entrou com a máscara e depois a tirou. Pelo que viu, a moça com a moto estava no local esperando o assaltante para fugirem. Não sabe o valor levado da sorveteria. Acredita que o proprietário do estabelecimento não recuperou o dinheiro. Não conhecia o assaltante, que era magro, de estatura mediana, pardo e tinha uma tatuagem de lágrima no rosto. Havia duas câmeras no local e a ação foi gravada. Reconheceu em Juízo, sem dúvidas, o homem identificado com o número dois (ou seja, o réu) como sendo a pessoa que assaltou a sorveteria.

No mesmo sentido, o ofendido Everson Renan Garcia, ouvido em Juízo, disse que o acusado chegou ao local pedindo um açaí disfarçadamente. Foi buscar o açaí no outro salão ao lado e, quando retornou ao salão onde realiza as vendas, o réu logo lhe rendeu. Também estavam no local sua mãe e uma funcionária. Foi o primeiro a ser rendido. O acusado colocou o revólver em sua cara e falou que era um assalto. O revólver parecia ser de calibre 22 ou 32 e era meio marrom ou preto. O réu falou "quero o dinheiro, perdeu, perdeu". Dirigiu-se até o caixa e o acusado quis levar também os celulares, mas chegou um cliente e ele acabou não os levando. O réu subtraiu somente dinheiro, R\$ 440,00 aproximadamente, que estava no interior do caixa. O acusado estava com máscara cirúrgica e pôde ver mais a tatuagem de pingo de choro que ele tinha no rosto. Fez reconhecimento na delegacia. Não teve dúvida quanto ao reconhecimento do réu, realizado em uma sala própria na Delegacia. Não recuperou o dinheiro. Não conhecia o acusado. O réu queria devolver o dinheiro, mas como já havia registrado o B.O., falou para ele que não queria mais o numerário. Um conhecido seu conhecia o acusado de vista e conversou com ele, ocasião em que o réu falou sobre o interesse em devolver o dinheiro. O acusado disse que pegou o dinheiro porque tem criança e estava precisando. O seu conhecido não falou o nome do réu. Não teve contato com o acusado para devolução do dinheiro. Mostrou o vídeo para esse conhecido e ele já conhecia o réu. Apresentou o vídeo na delegacia. Reconheceu em juízo, sem dúvidas, o homem identificado com o número dois (ou seja, o réu) como sendo a pessoa que assaltou a sorveteria.

Como já consignado, os elementos de convicção são fartos na demonstração da responsabilidade criminal do acusado. De fato, ficou categoricamente comprovado que no dia dos fatos o réu e uma comparsa não identificada se dirigiram à sorveteria das vítimas Everson e Celice com o propósito de roubar valores existentes no caixa da empresa. Enquanto a comparsa permaneceu com a motocicleta do lado de fora, esperando o acusado para dar fuga, este ingressou na loja e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, rendeu as vítimas e uma funcionária que lá se encontrava, apoderou-se do dinheiro que havia no caixa e de lá se evadiu com a comparsa.

As causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, inciso I, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal ficam reconhecidas.

Com efeito, restou demonstrado que o acusado e terceira pessoa que não foi identificada praticaram o crime numa perfeita conjugação de vontades, com unidade de desígnios, cada qual desempenhando uma função específica para o sucesso da

empreitada, tendo o acusado sido responsável por ingressar no estabelecimento, render as vítimas e subtrair-lhes os valores, ao passo que a terceira ficou incumbida de levar o réu até o local com uma motocicleta e esperá-lo para dar fuga. E, para tanto, valeram-se de arma de fogo, que foi efetivamente utilizada pelo réu durante a empreitada criminosa, como relatado pelas vítimas e por ele próprio admitido em Juízo. Ressalto que o fato de a arma não ter sido apreendida não impede o reconhecimento da causa de aumento, porque "em sede de crime de roubo, a declaração da vítima é prova suficiente ao reconhecimento da qualificadora de emprego de arma, ainda que o instrumento não seja apreendido" (TACRIM-SP - RJTACrim 43/402).

A tese de inconstitucionalidade material da expressão "2/3 (dois terços)" contida art. 157, § 2º-A, do Código Penal, arguida pela Defesa, não merece acolhimento. Conforme já decidiu o E. TJ/SP: "(...) De início, ressalto que o órgão fracionado pode, sem ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Magna, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Primeiro porque todas as leis gozam de presunção de constitucionalidade, não sendo necessária declaração formal para tanto e tampouco submissão ao Órgão Especial. Segundo porque assim dispõe o Código de Processo Civil ao tratar do incidente de arguição de inconstitucionalidade nos Tribunais. Com efeito, o referido código dispõe que arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, o relator submeterá o feito à câmara que competir o conhecimento do processo e, rejeitada tal arguição, prosseguirá o julgamento (art. 949, I do CPC). Dito isto, anoto que a Lei nº 13.654, de 2018, a qual revogou o inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal e incluiu ao dispositivo o §2º-A, dispondo que a pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo (inciso I), encontra-se em perfeita consonância com a Constituição Federal. Afinal, o delito de roubo é um crime complexo que atinge não só o patrimônio, mas também a integridade física da pessoa, mormente se praticado mediante o emprego de arma de fogo. Assim, porque ofende mais de um bem jurídico e porque, em última análise, trata de proteção à vida, o aumento de pena para o caso de emprego de arma de fogo, antes de contrariar o princípio da proporcionalidade, a ele se adequa, na medida em que ajusta a proteção antes insuficiente conferida pelo Direito Penal ao bem jurídico da mais elevada importância, no caso a vida." (TJ/SP; Apelação Criminal nº 0000961-52.2018.8.26.0537; Relator(a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 06/06/2019). No mesmo sentido: "Com efeito, tenho que o legislador, de forma consciente da necessidade de se adotar uma resposta penal adequada a garantir a proteção penal ao bem jurídico tutelado nos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, imprimiu maior rigidez ao punir o agente que se utiliza de arma de fogo, decorrendo tal prerrogativa da política pública, não podendo o Judiciário, em intervenção indevida na linha de divisão de poderes, alterar a finalidade da lei, se não há flagrante contradição ou desvio de finalidade. Daí porque não ser possível reconhecer, de forma incidental, a inconstitucionalidade do artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, até mesmo em observância a competência de reserva do plenário (art. 97, CF). Há que se dizer ainda que a opção do legislador para impor o aumento da fração de 2/3, observado foi o devido processo legislativo e a vontade expressa do legislador, sendo referida norma válida e vinculante, o que afasta também a pretensão da d. defesa, deduzida de forma alternativa, de aplicar-se a redação revogada do inciso I do art. 157, do Código Penal" (TJ/SP, Apelação nº 0046228-53.2018.8.26.0050, 16ª Câmara Criminal, Rel. Desembargador Newton Neves, julgado em 31.10.2018). Portanto, não há dúvida de que o crime de roubo com emprego de arma de fogo potencializa o risco à integridade física e à vida da vítima, bens igualmente tutelados pela norma penal, e não só ao patrimônio alheio. O legislador, investido de sua prerrogativa de representante eleito democraticamente, valendo-se de política criminal legítima, houve por bem prever maior recrudescimento em crimes desta natureza com base na necessidade de se proteger com mais rigor o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. Assim, forçoso reconhecer que a Lei nº 13.654/2018 é válida, constitucional e se encontra vigente, razão pela

qual inviável o seu afastamento.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e ante a sua culpabilidade impõe-se-lhe a condenação e a pena que passo a dosar, eis que inexistem quaisquer justificativas ou dirimentes a reconhecer.

Da análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta antecedentes criminais pela prática de furto (processos 24923-77.2012 e 38333-30.2009, conforme certidão de fls. 140/146). Atendendo, ainda, à personalidade e conduta social do acusado, voltada para a prática reiterada de crimes (foi, ainda, condenado definitivamente por outro roubo, praticado após o delito ora apurado – fls. 142), aos motivos, circunstâncias e consequências do delito (as vítimas não recuperaram os valores subtraídos, suportando o prejuízo), fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco anos de reclusão e doze dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, observo que o acusado possui duas condenações geradoras de reincidência, uma delas específica (processos 7343-63.2014 ---lesão corporal--- e 19245-13.2014 ---roubo majorado---, conforme certidão de fls. 140/146), o que implica em maior reprovabilidade da conduta e impede a simples compensação da agravante com a atenuante da confissão, razão pela qual aumento a pena base em $\frac{1}{4}$, totalizando, assim, seis anos e três meses de reclusão e quinze dias-multa. Presente, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea, reduz a pena em $\frac{1}{6}$, o que resulta no importe de cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão e doze dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria penal, presentes as causas de aumento do inciso II do § 2º e do inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, e levando-se em consideração o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, o qual prevê que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial o Juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a que mais aumente, majoro a pena fixada em $\frac{2}{3}$ (inciso I, do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal), totalizando, assim, oito anos, oito meses e cinco dias de reclusão e vinte dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras de reprimenda, torno definitiva a pena aplicada, calculada a de multa no patamar mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra DIEGO FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de oito anos, oito meses e cinco dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a vinte dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica não só porque o réu é reincidente específico, mas também porque a sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm a sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade abstrata do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, praticado em concurso e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o que exige maior reprovação diante da extrema periculosidade da conduta. Neste sentido: “RESISTÊNCIA E ROUBO QUALIFICADO TENTADO - Prescrição da pretensão punitiva caracterizada quanto ao primeiro delito. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime remanescente. PENA - Majoração da pena de roubo diante da presença de duas causas de aumento. Necessidade. Adequação das penas.

REGIME PRISIONAL - Inicial fechado é o que convém a autor de crime patrimonial violento. Recurso ministerial parcialmente acolhido e desprovido o apelo defensivo" (TJSP; Apelação Criminal 0000691-47.2017.8.26.0542; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

O réu teve contra si decretada prisão preventiva a fls. 92/93, encontrando-se detido até hoje. Assim, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o "fumus boni iuris", preso, após a prolação de sentença, surge a certeza, que exclui a possibilidade do recurso em liberdade (RJDTACRIM 13/181). Logo, não poderá recorrer em liberdade, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que a decretou.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Araçatuba, 21 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA